



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2013.0000623020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0011801-47.2008.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante THIAGO SILVA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para, afastada a incidência da Lei nº 12.015/2009, dar o Apelante como incurso no art. 214 c.c. o art. 226, II, na redação do Código Penal anterior ao aludido Diploma Legal, diminuindo-se a pena a 9 (nove) anos de reclusão, mantendo-se no mais, a r. sentença. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS BUENO (Presidente) e PINHEIRO FRANCO.

São Paulo, 11 de outubro de 2013.

EDUARDO ABDALLA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0011801.47.2008.8.26.0481
 Comarca: PRESIDENTE EPITÁCIO
 Juízo de Origem: 2ª VARA JUDICIAL
 Apelante: THIAGO SILVA DE OLIVEIRA
 Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
 Magistrada Sentenciante: Dra. Priscila Midori Maizato
 VOTO 00576

ESTUPRO DE VULNERÁVEL CIRCUNSTANCIADO. Apelação criminal. Autoria e materialidade bem delineadas. Reconhecimento de que o crime de atentado violento ao pudor contra infante, vigente à época dos fatos, é mais benéfico, na hipótese, do que o novo art. 217-A, do CP, introduzido pela Lei nº 12.015/2009. Manutenção da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, diante da demonstração de que o Apelante detinha autoridade sobre a menor, na ausência da genitora. Penas diminuídas para atender a modificação do tipo. Regime fechado mantido.

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por THIAGO SILVA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida nos autos do Processo nº 481.01.2008.011801-6, do Juízo da 2ª Vara Judicial de Presidente Epitácio, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 217-A, c.c. o art. 226, II, do Código Penal, concedido o apelo em liberdade (fls. 224/236).

Inconformado, pleiteia absolvição, diante da fragilidade das provas. Aduz, em caso de manutenção da condenação, que o Apelante incorreu nas penas do art. 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos, e mais benéfico. Além



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

disso, requer o afastamento da causa de aumento (fls. 252/270).

Contrariado o recurso, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo seu improvimento (fls. 272/273 e 279/282).

É O RELATÓRIO.

O Apelante foi processado porque constrangeu a infante Giovana, com então nove anos de idade, a praticar ato libidinoso diverso de conjunção carnal.

Judicialmente, negou a autoria, acreditando que a imputação seria fruto do relacionamento amoroso que tem com a genitora da vítima, bem como da disputa judicial para a guarda da menor, travada pelo ex-marido (fls. 142).

Todavia, sua versão para os fatos é isolada do restante da prova, sobretudo dos relatos seguros da vítima, que, como se sabe,

“é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos” (STJ – AgRg no REsp 1346774/SC - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Quinta Turma - DJe 01/02/2013)

Aliás, é também esse o posicionamento dos demais Desembargadores desta Câmara, confira-se:

TJSP – Ap. 0009569-84.2005.8.26.0152 – Des. PINHEIRO FRANCO - 5ª Câmara de Direito Criminal – j. em 01 de junho de 2006. TJSP – Ap. 0059484-07.2010.8.26.0224 – Des. CARLOS BUENO – 10ª Câmara de Direito Criminal – j. em 23 de maio de 2013.

Segundo os relatos prestados em todas as oportunidades, THIAGO namorava sua mãe e pernoitava em sua casa aos finais de semana. Em um sábado, aproveitando-se da ausência de sua genitora, que havia saído para trabalhar, ele a levou para o quarto, tirou suas roupas e em seguida passou a esfregar o pênis em seu ânus e os dedos em sua vagina.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Suprida sua concupiscência, THIAGO lhe disse para não contar nada a ninguém, caso contrário a mataria (fls. 33 e 124/125).

Por sua vez, *Luis de Souza*, genitor da vítima, declarou que a criança contou o ocorrido primeiro à mãe e depois a ele. Acrescentou que, enquanto a menina residia com a mãe, não tentou obter sua guarda (fls. 123).

Vale registrar que nesse tipo de crime é dispensável o laudo pericial que ateste a violência sofrida, uma vez que se trata de delito que, na maioria das vezes, não deixa vestígios, de modo que a palavra da ofendida, quando escorada em outros elementos de convicção, como na hipótese, é capaz de comprovar a autoria do crime. Nesse sentido, confira-se: STJ - REsp 1248354 - Rel. Min. LAURITA VAZ – publicado em 20/04/2012.

E nem se alegue estar a infante sofrendo de alienação parental, porquanto o laudo de fls. 181 rechaça essa possibilidade: *“ressalta-se, no entanto, não haver indicativos para implantação de falsa memória ou para alienação parental, o que por exemplo implicaria no apego excessivo à figura acusadora, no caso o genitor que concretizou a denúncia; na ausência de ambivalência ou na defesa deliberada do genitor alienador, entre outras”*.

Além disso, como bem ponderou o R. Juízo, *“referidas alegações poderiam ter sido demonstradas com cópias do processo de guarda, ou ainda mediante constatação de anterior comportamento reprovável do genitor a fim de denegrir a imagem da ex-esposa para obter a guarda das crianças. Veja-se que não há nada nos autos que confirme as afirmações da defesa, ônus que a mesmas competia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal”* (fls. 229).

Destarte, de rigor a manutenção da condenação.

Em que pese o entendimento de 1º Grau, o art. 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos, é mais



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

benéfico na hipótese (pena mínima de 6 anos) – e, em consequência amoldar a conduta ao crime de estupro de vulnerável, criado pela Lei nº 12.015/2009 – destacou a aplicabilidade da majorante prevista no art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos em conjunto com o tipo derogado, consignando, destarte, que a somatória das penas previstas no art. 214, c.c. o art. 226, II, ambos do Código Penal e com o art. 9º da Lei nº 8.072/90 seria mais prejudicial do que as previstas no art. 217-A c.c. o art. 226, II, ambos do Código Penal.

Todavia, cumpre observar que a causa de aumento prevista na Lei Especial somente seria aplicável se a conduta praticada contra infante resultasse lesão corporal de natureza grave, hipótese não constatada nos autos, felizmente.

Confira-se:

“(...) A base foi fixada no mínimo e majorada de metade por força do art. 9º, da Lei 8.072/90. Mas o acréscimo pela circunstância prevista no referido artigo não pode ser aplicado. É que sem constatação de lesões corporais graves, dada a expressa referência ao artigo 223 do código Penal, não se plica a previsão da lei especial” (TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação nº 990.08.088231-7 – Rel. Des. PINHEIRO FRANCO – J. 13.11.2008).

Assim, a dosimetria será refeita, de modo a se adequar as penas ao crime de atentado violento ao pudor, vigente à época dos fatos, circunstanciado, por ser mais benéfico.

A pena-base parte do mínimo de 6 anos de reclusão.

No tocante à causa de aumento, cumpre-se anotar que, embora o Apelante mantivesse namoro e não união estável com a genitora da vítima à época dos fatos, as circunstâncias peculiares do caso demonstram que ele detinha



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

autoridade sobre a vítima – *por qualquer título* - quando a mãe saía para trabalhar (ou ir à academia) e a deixava sob os seus cuidados, o que é suficiente para caracterizar a majorante, *ex vi* o art. 226, II, do Código Penal.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

“Não se exige a coabitação para a aplicação da causa de aumento de pena do art. 226 , II , do Código Penal , se as circunstâncias do caso concreto demonstram que o agente detinha autoridade sobre a vítima, dela abusando para o cometimento do crime” (TJSC - Apelação Criminal 147275 – Relator JOSÉ CARLOS CARSTENS KÖHLER – publicado em 09/05/2011).

Assim, a pena sofre acréscimo mínimo de 1/2, tornando-se definitiva em 9 anos de reclusão.

Por fim, o regime inicial fechado é o único compatível com o crime perpetrado, que tem natureza hedionda, nos termos da regra estatuída no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. Além disso, o montante de pena aplicado inviabiliza a fixação de regime mais brando, consoante art. 33, § 2º, a), do Código Penal.

Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso para, afastada a incidência da Lei nº 12.015/2009, dar o Apelante como incurso no art. 214 c.c. o art. 226, II, na redação do Código Penal anterior ao aludido Diploma Legal, diminuindo-se a pena a 9 (nove) anos de reclusão, mantendo-se no mais, a r. sentença. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica